

1500750-10.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/10/2022

... na denúncia, o acusado confessou o tráfico em seu interrogatório policial, ocasião em que se fazia acompanhar por defensora constituída (fls. 19/20).

Aliás, por tal circunstância, cai por terra sua alegação dada em interrogatório judicial de que apenas confessou o tráfico perante a autoridade policial por estar sob efeito de droga.

E tem mais: normalmente, o usuário, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Epitácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500750-10.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500750-10.2020.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2234831/2020 - 2º Distrito Policial de Lorena, 13731445 - 2º Distrito Policial de Lorena, 1205/20/204 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06 (fls. 105/107).

Oferecida a denúncia, o réu apresentou defesa prévia (fls. 135/136). A denúncia foi recebida em 20 de julho de 2022 (fls. 158/159).

No curso da instrução foram ouvidas duas testemunhas e uma informante judicial e, na sequência, realizado o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em debates orais (mídia - fls. 200/201).

O Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal, com a condenação do acusado pelo delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e sua absolvição pelo crime do artigo 35, da mesma Lei.

Já a defesa, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para aquela prevista no tipo penal do artigo 28, da Lei 11.343/06; ou, ainda, em caso de condenação nos moldes da incoativa, pela fixação da pena no mínimo legal; afastamento da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente; a aplicação da redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da mesma Lei; e a concessão do apelo em liberdade.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/08), auto de exibição e apreensão (fls. 13/15), laudo de constatação provisória (fls. 49/53) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 196/199), com resultado positivo para "cocaína" e "tetrahidrocannabinol - maconha - THC", substâncias presentes na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório.

A prova de autoria também é indubitosa. Senão vejamos.

O policial militar Jaques Anderson Máximo contou que estava em patrulhamento de rotina quando, ao entrar no bairro Cecap, notou que duas pessoas correram, resolvendo abordá-las. Uma delas, o réu, foi flagrado na posse de vinte e dois pinos de "cocaína", uma porção de "maconha" e dinheiro. Já com o menor que o acompanhava, apreenderam-se mais entorpecentes e um aparelho celular. De acordo com o depoente, o acusado dissera admitiu que ali traficava cada pino de "cocaína" por dez reais, enquanto o adolescente o auxiliava, os guardando e buscando outros entorpecentes, escondidos em um terreno baldio próximo. Na sequência, dirigiu-se ao terreno mencionado, indicado pelo menor, onde apreenderam mais pinos de "cocaína", semelhantes àqueles localizados com a dupla, e "maconha". Afirmou que os dois negaram que este último entorpecente lhes pertencessem, e que não os conhecia até o dia dos fatos.

Seu companheiro de farda Elenilson Daniel dos Santos fez coro à sua fala. Acrescentou dizendo que havia outras pessoas na via pública, porém, não próximas aos dois, quando estes tentaram escapar da ação policial.

Já a genitora do acusado (Roseli Rodrigues de Oliveira) pouco acrescentou, vez que presenciou os fatos. Limitou-se a dizer que o filho é dependente químico.

Por sua vez, o réu em seu interrogatório, declarou que as drogas que trazia consigo destinavam-se ao seu próprio consumo. Negou que conhecesse o adolescente citado na denúncia; que tenha tentado fugir os agentes públicos; ou, ainda, admitido a prática do tráfico aos policiais militares durante sua abordagem. Questionado, negou também o teor do interrogatório prestado em sede policial, dizendo que estava sob efeito de drogas no momento. Ao final, disse que foi o menor quem indicou o local onde as outras drogas estavam escondidas (terreno baldio).

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a negativa isolada do acusado não é suficiente para impedir sua condenação.

Inicialmente, insta registrar a ampla credibilidade que detém as palavras de policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública.

Neste sentido, confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça deste estado:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim é, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas também por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

Frise-se que os policiais militares envolvidos na presente ocorrência sequer conheciam o réu até o dia dos fatos, até porque lotados no Batalhão de Ações Especiais de Polícia - BAEP, sediado em São José dos Campos/SP.

Mas não é só. Existe ainda mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país

pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade do testemunho de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

“Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisum o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados”. (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Fixada tal diretriz, verifico que o caso dos autos é mais um daqueles em que o réu tenta, em vão, desacreditar a fala das testemunhas policiais, sem ao menos, produzir um início de prova do que alega.

Perceba-se que, ao contrário das testemunhas policiais, as quais desde a fase inquisitiva apresentam enredo uniforme, crível e harmônico, em linha com a dinâmica fática exposta na denúncia, o acusado confessou o tráfico em seu interrogatório policial, ocasião em que se fazia acompanhar por defensora constituída (fls. 19/20).

Aliás, por tal circunstância, cai por terra sua alegação dada em interrogatório judicial de que apenas confessou o tráfico perante a autoridade policial por estar sob efeito de droga.

E tem mais: normalmente, o usuário, em razão da vontade incontrolável do vício, utiliza todo o dinheiro disponível para aquisição de drogas. Não por acaso, um dos motivos para essas substâncias serem proibidas é exatamente a dependência que elas causam, a ponto de levar o usuário e, na maioria das vezes, sua família à insolvência.

Logo, a apreensão de valores na posse do acusado é mais um elemento a indicar o tráfico.

Não se está aqui afastando a possibilidade do réu, eventualmente ser igualmente usuário de “cocaína”, conforme afixado por sua genitora, circunstância que não lhe impede, contudo, de vendê-la a terceiros, ou seja, de praticar o delito de tráfico de drogas. São situações absolutamente distintas.

Seguem julgados com o mesmo entendimento:

“Apelações criminais. (...) Não há possibilidade de se desclassificar as condutas para mero porte de drogas, certo que a jurisprudência não descarta a figura do usuário/traficante. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...) 6-) Recursos presos”. (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator: Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

“Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...) Condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma, a qual possui conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas (...) Dado parcial provimento ao recurso”. (TJSP; Apelação Criminal 0002190-02.2017.8.26.0628; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019) (Sublinhados meus).

Por fim, cabe esclarecer que apenas a prática de uma das condutas tipificadas no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos é suficiente para configurar tal delito, afigurando-se desnecessário que o agente seja flagrado em atos de efetiva mercancia. A finalidade mercantil é demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, como na hipótese dos autos, à luz do volume e diversidade das drogas; apreensão de dinheiro; a natureza do local de sua abordagem; modus operandi; etc.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Portanto, de rigor a condenação do réu pelo delito de tráfico.

Lado outro, com relação ao crime do artigo 35, da Lei em assunto, entendo que as provas não comprovaram a associação entre o réu e o menor M.M.M.

Convém lembrar que não basta para subsumir a conduta em estudo ao tipo do artigo 35, da legislação de drogas, a presença de dois ou mais agentes. É imprescindível que se revele o animus associativo, a estabilidade, permanência e organização do grupo, com funções pré-determinadas entre seus membros, bem como relação de hierarquia entre eles.

No caso dos autos, não foram colhidos outros elementos que demonstrassem tais requisitos.

Não se olvida das notícias trazidas pela testemunha dando conta de que o adolescente seria o responsável por recolher o dinheiro e abastecer o acusado com os entorpecentes, para que ele realizasse a venda aos usuários, contudo, tal

elemento, isolado, não é suficiente para comprovar o animus associativo entre os dois, hierarquia, permanência etc, mostrando-se, portanto, insuficientes para a condenação do acusado.

Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e associação. (...) Associação – provas insuficientes. O crime em tela exige a vontade de dois ou mais agentes se associarem (animus associativo) e sua consumação se dá com a reunião estável e permanente, dispensando a prática do crime-fim. Não se demonstrou, contudo, mínima organização e hierarquia entre eles o que, após cotejar todos os elementos analíticos inseridos nos autos, não emerge com clareza meridiana o vínculo associativo. (...) Recurso parcialmente provido, nos termos do v. Acórdão”. (TJSP; Apelação Criminal 0002107-90.2016.8.26.0443; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piedade - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017) (ênfase minha).

Não por outro motivo, o próprio Ministério Público requereu a sua absolvição.

Passo à modulação penal.

O acusado é tecnicamente primário e de bons antecedentes (fls. 178/179).

Contudo, há que se destacar a maior reprovabilidade da conduta censurada. O tipo em questão visa tutelar bem jurídico coletivo (saúde pública). Assim, quanto maior a quantidade e diversidade de droga envolvida, mais elevado será o risco gerado àquele.

Pois bem. No caso dos autos, tratar-se de 1.432,15 gramas de “maconha” (massa líquida), e 71,34 gramas de “cocaína” (massa líquida), ou seja, aproximadamente um quilo e meio de drogas, o que demonstra que a conduta em tela atingiria centenas, quiçá milhares de usuários loarenenses e moradores de cidades vizinhas que lutam contra o vício maligno.

Ademais, deixar de valor negativamente tal circunstância significaria negar vigência aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ambos de estatutura constitucional, por equipar a conduta àquelas envolvendo pequena quantidade de narcóticos.

Portanto, à luz de tais circunstâncias, hei por bem fixar a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do piso legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na etapa intermediária, inexistem agravantes ou atenuantes.

Não é o caso de reconhecer a atenuante da confissão, pois como visto, o réu negou o tráfico, assumindo conduta menos gravosa como forma de se livrar da acusação original.

Neste sentido:

“Ação Penal – (...) – Sentença condenatória – (...) Pleito para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea – Relato dos fatos, acompanhado de teses defensivas e exculpatórias – Caracterização de ‘confissão qualificada’ pelo magistrado, que não admite a redução da pena – Inexistência de confissão para este Relator – (...) – Regime fechado – Recurso da ré Rosilei provido em parte e recurso do réu Vitor José provido em parte, em menor extensão”. (TJSP; Apelação Criminal 1500289-96.2019.8.26.0613; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020) (Sublinhado meu).

Na última etapa, reconheço a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, vez que comprovado o envolvimento do menor M.M.M no crime, conforme demonstrou a prova oral.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de DROGAS. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos. (...) Condenação mantida. Dosimetria. Afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. Desacolhimento. Majorante de caráter objetivo, bastando que o delito seja praticado com a participação de adolescente, o que restou suficientemente comprovado. Desnecessidade de demonstração da efetiva corrupção do menor para a incidência da causa de aumento em questão. (...) Recursos desprovidos". (TJSP; Apelação Criminal 1501615-88.2021.8.26.0559; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirassol - 3ª Vara; Data do Julgamento: 02/06/2022; Data de Registro: 02/06/2022) (Ênfase minha).

Assim, elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à míngua outras causas modificadoras.

Apenas para que não seja alegada omissão do presente julgado, o réu não faz jus à redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, vez que as circunstâncias do caso concreto revelam sua profunda intimidade com o narcotráfico, a despeito da sua condição de bons antecedentes aos olhos da lei.

Afinal, o acusado não comprovou a realização de ofício legítimo para seu sustento, sequer apresentando qualquer ocupação lícita, ainda que estudantil.

Como se não bastasse, o réu já foi condenado em primeiro grau de jurisdição em feito distinto, justamente pela prática de crime idêntico praticado após os fatos aqui julgados (autos nº 1530366-11.2021.8.26.0228 - fls. 178).

A propósito, informativo do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

"É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06" (Informativo nº 0596, Publicação: 1º de março de 2017; STJ; EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por maioria, julgado em 14/12/2016, DJe 1/2/2017).

E tem mais: traficante algum confiaria à a um neófito, a quantidade e diversidade de drogas encontradas sob sua guarda, a reforçar a conclusão acima exarada.

Neste sentido, trago à colação, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). 1. Na hipótese dos autos, a causa especial de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 foi afastada não somente pela quantidade de drogas apreendidas - 17kg de maconha -, mas, também, em virtude da existência de outros elementos fáticos, notadamente a apreensão de balança de precisão e outros apetrechos para a prática da traficância. (...) 2. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 707.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022) (Sublinhei).

Ou seja, tais circunstâncias indicam que o indigitado é pessoa que vem trilhando o caminho do mundo do crime, dedicando-se às atividades criminosas, situação que afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena, visto que não existe prova direta dessa circunstância, "os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'", como bem lançado pelo Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, em julgado que assim se encontra a ementa:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada. (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

A redutora em comento destina-se apenas aquele que age por um impulso, em situação isolada, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico cuidou somente de um desvio em sua vida, o que não é o caso destes autos.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 33, § 3º, do Código Penal).

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada,

estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Incabível a aplicação de medidas despenalizadoras por se mostrarem incompatíveis com a natureza hedionda do crime, ora em voga. Ainda que assim não fosse, o montante de pena aplicado, por si só, as inviabilizaria.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, forte nos artigos 43, da Lei 11.343/06, e 49, § 2º, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, por violação do tipo penal previsto no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, diária mínima, absolvendo-o da imputação restante lhe dirigida na denúncia (artigo 35, da Lei 11.343/06), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processo Penal.

Nego o apelo em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva do acusado transformaram-se em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta a esse acusado e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual, em especial, de acusado que, após ser agraciado com liberdade provisória, pratica novo delito de tráfico, tal como acima mencionado.

Assim, visando assegurar a aplicação da lei penal, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas - Preliminar - Apelo em liberdade - Impossibilidade - Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos - Preliminar rejeitada - Recurso não provido. Tráfico de Drogas - (...) - Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

No entanto, havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória.

Custas pelo vencido.

Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Apelo defensivo pelo abrandamento punitivo, por meio da mitigação das penas iniciais; do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; do deferimento do redutor da forma "privilegiada"; da atenuação do regime inicial; da revogação da prisão preventiva; e da gratuidade judiciária. (...). - (vi) Gratuidade judiciária. Benefício não concedido. Medida destinada, por excelência, a assegurar o acesso à

Justiça. Réu que não logrou comprovar a hipossuficiência material. Assistência por defensores constituídos. Não incidência da presunção relativa de precariedade econômica. Pleitos afastados, com confirmação das penas. Negado provimento, na parte conhecida". (TJSP; Apelação Criminal 1500802-96.2019.8.26.0279; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021) (Sublinhado meu).

Caso ainda não se tenha feito, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos apreendidos, oficiando-se à Autoridade Policial para proceder à sua destruição.

Decreto o perdimento da quantia apreendida em favor da União, forte no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/06. Expeça-se o necessário com o trânsito em julgado.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - Preliminar - Restituição de valor apreendido - Desacolhimento - Caderno processual que indica que o numerário questionado é proveniente da prática do tráfico de drogas - Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do dinheiro apreendido - Perda em favor da união corretamente determinada - Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei n.º 11.343/06 - Preliminar rejeitada. (...) Condenação mantida. (...) - Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1500220-88.2021.8.26.0356; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirandópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021) (Ênfase minha).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução; b) Intime-se o acusado para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu para cumprimento do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial, nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento do processo de execução, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA